

1501888-44.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas."

(TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a):

Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 7, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3372-3084, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501888-44.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2333893/2021 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVERTON CRISTIANO LOPES ROQUE

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 26 dias do mês de abril de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Denis Peixoto Parron e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) EVERTON CRISTIANO LOPES ROQUE, e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Vinicius de Castro Avila, Gabriel Magrini, Marlon Denis de Souza Felipe e Thais Stefane Silva Santana. Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) comuns (Vinicius e Marlon) pelo sistema virtual e, em seguida, interrogado(a)(s) o(a)(s) réu(ré)(s). Pelas partes foi dito que desistem da oitiva das testemunhas Gabriel Magrini e

Thais Stefane Silva Santana.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

Homologo a desistência das partes em relação às testemunhas Gabriel Magrini e Thais Stefane Silva Santana.

"Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM. Juíza, EVERTON CRISTIANO LOPES ROQUE está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Feito processado com regularidade.

Procede a ação penal.

DOS FATOS, COM INDICACAO DAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de dezembro de 2021, por volta de 11h00min, em via pública compreendida entre a Rua Dom Manuel, Rua do Enxofre e Travessa Salvador, n.º 173, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, EVERTON CRISTIANO LOPES ROQUE, qualificado e indiciado às fls. 07/08 e 27/28, trazia consigo e transportava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 96 (noventa e seis) invólucros plásticos contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 9,6g (nove gramas e seis decigramas), e 49 (quarenta e nove) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 12,8g (doze gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, o denunciado - que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas - trazia consigo e transportava, no veículo GM/Monza, placas BNL-1377, porções de crack e cocaína para comercialização. Ocorre que, ao realizar manobra de trânsito proibida, foi interpelado por policiais militares em patrulhamento.

Desobedecendo às ordens de parada, iniciou fuga pelas vias acima descritas.

Em dado momento, EVERTON subiu com o veículo na calçada e, diante do desligamento do motor e da aproximação policial, dispensou uma bolsa pela janela. Na sequência, foi abordado juntamente com outros três ocupantes do carro.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado.

Nas proximidades, foi encontrada a bolsa dispensada por EVERTON, a qual continha 96 (noventa e seis) porções de crack e 49 (quarenta e nove) eppendorfs de cocaína.

Na delegacia, o denunciado admitiu a propriedade das drogas, mas alegou que era para uso pessoal (fls. 07/08).

Os demais ocupantes do veículo disseram que estavam de carona e desconheciam a existência dos ilícitos no veículo (fls. 04, 05 e 06) - dois dos passageiros (fls. 05 e 06) presenciaram EVERTON jogando a bolsa pela janela antes da abordagem policial.

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 16/17, foto fls. 18 e laudo pericial de constatação fls. 21/25).

Diante das circunstâncias, notadamente as condições pessoais do denunciado, a fuga, a tentativa de livrar-se da droga, o relato dos passageiros e a apreensão de porções de crack e cocaína em quantidade e forma incompatíveis com a mera alegação de uso pessoal, é certo que o denunciado trazia consigo e transportava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

DA PROVA NA FASE JUDICIAL

Marlon Denis de Souza Felipe disse que pegou carona com o réu EVERTON, foi ele quem ofereceu a carona porque ele estava interessado na Tais. Foram até a casa dele e ele pegou uma bolsa. Ele estava de carro. Estavam inicialmente em cinco, depois ficaram em quatro no carro. Não entraram na casa dele. Ele saiu da casa com uma bolsa. Deixaram o local de carro e depois, viram a polícia. Ele começou a fugir com o carro. Ele parou na calçada e jogou a bolsa na calçada. Era a mesma bolsa que ele tinha pegado na casa dele. A polícia abordou todos. Não sabia o que tinha dentro da bolsa. Os policiais encontraram droga na bolsa, mas não sabe a quantidade. Não conhecia o réu.

Vinicius de Castro Ávila - Policial Militar - disse que estava em patrulhamento e

se aproximou do veículo do réu porque o surpreendera fazendo manobra em alta velocidade. Iniciaram-se fuga e perseguição, até que o réu subiu em uma calçada e o motor do veículo parou. Ele dispensou uma sacola, que foi recuperada, constatando-se que tinha droga. Tinham "umas" cinco pessoas. Quem dispensou a mochila foi o motorista, ou seja, o réu, que assumiu a propriedade do entorpecente. Os demais ocupantes disseram que pegaram carona com o réu de um baile funk e que não sabiam que tinha droga na mochila. Eram noventa e seis invólucros contendo crack e quarenta e nove eppendorfs com cocaína. Não conhecia o réu. Ele confirmou que os demais passageiros eram apenas carona.

No mesmo sentido, Gabriel Magrini, Policial Militar, e Thaís Stefane da Silva Santana, fls. 06.

O réu confessou parcialmente os fatos. Disse que tinha vendido drogas e que a droga que foi apreendida era para uso próprio. Foi abordado porque fez manobra irregular no trânsito e fugiu porque ficou com medo de perder o carro. Teve recaída no uso de drogas depois que brigou com a mulher. Já tinha vendido para umas duas ou três pessoas do baile. Confirma que dispensou a bolsa quando foi abordado. Mas depois assumiu que a droga era de sua responsabilidade. As pessoas que estavam no carro nem sabiam que tinha droga na bolsa.

Da caracterização do crime de tráfico de drogas:

As palavras dos agentes policiais merecem credibilidade e possuem força probatória suficiente para a prolação da sentença condenatória, mormente porque não conheciam o réu e não tinham motivo algum para incriminá-lo gratuitamente (Apelação Criminal nº 990.08.153847-4, 8ª Câmara Criminal, rel. Des. André de Oliveira, julgada em 13/03/2009).

Não procede a alegação do réu de que a droga era para uso próprio. O réu estava em um baile e tinha vendido algumas porções. Depois voltou para a casa para pegar mais droga e alegou que era para consumo próprio. Porém, o réu estava em poder de grande quantidade de drogas, incompatível com a posse para uso pessoal.

As provas angariadas não deixaram dúvidas acerca da configuração do tráfico de drogas.

Com relação ao argumento do réu de que não chegou a nada comercializar, nem se alegue que tal seria necessário, pois não é necessária a prática de ato de comércio, ainda mais quando não há dúvida de que o entorpecente seria destinado à venda. No ponto: "A prova mostra, ainda, que a droga era destinada ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento e pela postura do acusado, que inclusive admitiu o comércio espúrio. De mais a mais, nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado.

Dentro dessas premissas, não se tem dúvida de que o entorpecente apreendido seria destinado à venda, de sorte que o delito está bem caracterizado. A condenação do recorrente pelo tráfico, portanto, foi bem decretada." TJ/SP, 0005411-25.2010.8.26.0050 Apelação, Relator(a): Pinheiro Franco, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 10/11/2011, Data de registro: 11/11/2011).

Saliento que o fato de se declarar usuário de drogas, não afasta a possibilidade de que o mesmo exerça a traficância ilícita de entorpecentes, até porque muitos dependentes de tóxicos utilizam desse expediente para financiar o próprio vício. Nesse sentido: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229- 3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 10/498).

E não há se falar em absolvição fundada em suposta dificuldade financeira, uma vez que esta situação não caracteriza estado de necessidade, nem se amolda a qualquer excludente de culpabilidade. Além disso, não poderia o agente criminoso valer-se de meio ilícito para obter seu sustento. "Crime de tráfico - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Transporte interestadual - Confissão da ré que se ajusta a esse quadro - Estado de necessidade afastado - Justificativa de dificuldades financeiras que não afasta a

punibilidade - Pena base fixada no mínimo legal previsto, compensada a causa de aumento com a causa de redução por frações iguais - Pena adequada - Recurso não provido." (Apelação 990080746367, 16ª Câmara de Direito Criminal TJ/SP, relator Newton Neves, julgado em 23.03.10).

DA PENA

Folha de antecedentes e certidões já providenciadas (fls. 47/63): EVERTON CRISTIANO LOPES ROQUE ostenta maus antecedentes e reincidência específica - condenado por ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico nos autos n.º 0000301-66.2018.8.26.0599 (fls. 49: pena extinta em 14.03.2019) e 1542273-95.2018.8.26.0451 (fls. 51/52: pena extinta em 28.09.2021), por tráfico de drogas nos autos n.º 0005297-08.2014.8.26.0451 (fls. 49/50: pena extinta em 09.11.2017) e roubo circunstanciado nos autos n.º 0032148-55.2012.8.26.0451 (fls. 51: pena extinta em 09.11.2017).

Pena acima do mínimo legal.

Não é possível a diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Entendo não ser possível, também, pelo mesmo motivo, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Em que pese o Colendo Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei nº 11.343/06 por ocasião do julgamento do HC nº 97.256/RS, e a resolução do Senado Federal suspendendo a execução de parte do dispositivo legal, a vedação de se aplicar penas restritivas ao crime de tráfico continua sendo possível quando as circunstâncias do art. 44, III, do Código Penal indicarem não ser recomendável a substituição, como ocorre no caso em apreço. É que o STF afastou a proibição que a lei trazia, mas não tornou obrigatória a substituição. Esta somente será possível quando as circunstâncias do fato apontarem como suficiente e recomendável a substituição. E, definitivamente, não se demonstra razoável conceder tamanho beneplácito aos que praticam tão grave crime como o tratado nestes autos.

Ao contrário, estes merecem severa reprimenda, pois se trata de crime em que a base da sociedade é atingida, distorcendo regras e valores dos jovens, de forma a aumentar a já tão elevada criminalidade. O traficante age sem qualquer escrúpulo, com exclusiva intenção de lucro, não se importando em destruir diversos lares e famílias quando leva ou mantém no vício um de seus integrantes.

O legislador, ao equiparar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes aos crimes hediondos, em norma constitucional (art. 5º, XLIII, da CF), deixou claro seu intuito em dar tratamento rigoroso aos que praticam este crime, determinando, ainda, que o regime inicial de cumprimento de pena será, obrigatoriamente, o fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

O E. Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, embora sem impedimento legal, é incompatível com a condenação por crime hediondo, mesmo que equiparado, em razão da periculosidade social presumida, que incompatibiliza o autor do crime com atividades comunitárias ou assistenciais na medida em que o coloca em contato direto com grupo social passível de seu assédio. Ademais, em face do contexto em que o crime foi praticado, que exterioriza a personalidade do agente e seu desprezo pela vida em sociedade, eis que o envolvimento com o tráfico fomenta a multiplicação de outros crimes, não se mostra suficiente a referida benesse. Isso porque, com base no art. 44, III, do CP, tem-se que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos somente se mostra adequada quando suficiente ao atendimento das finalidades retributiva, preventiva e reprovadora da conduta, o que não se mostra no presente caso (TJ/SP, Apelação 0006123-68.2013.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, 13ª Câmara de Direito Criminal, v.u., Des. Rel. Augusto de Siqueira, j. em 08 de maio de 2014, publicada no dia 27 de maio de 2014).

Deve ser decretado o perdimento do dinheiro apreendido em poder do réu, com base no art. 63, Lei n. 11.343/06.

DO PEDIDO FINAL

Pela procedência da ação penal nos termos iniciais.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, Everton Cristiano Lopes Roque foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 92-94), no dia 08 de dezembro de 2021, por volta de 11h, em via pública compreendida entre a rua Dom Manuel, rua do Enxofre e Travessa Salvador, n.º 173, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Everton trazia consigo e transportava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 96 (noventa e seis) invólucros plásticos contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 9,6g (nove gramas e seis decigramas), e 49 (quarenta e nove) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 12,8g (doze gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, o réu trazia consigo e transportava, no veículo GM/Monza, placas BNL-1377, porções de crack e cocaína para comercialização. Ocorre que, ao realizar manobra de trânsito proibida, foi interpelado por policiais militares em patrulhamento. Desobedecendo às ordens de parada, iniciou fuga pelas vias acima descritas. Em dado momento, Everton subiu com o veículo na calçada e, diante do desligamento do motor e da aproximação policial, dispensou uma bolsa pela janela. Na sequência, foi abordado juntamente com outros três ocupantes do carro. Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Nas proximidades, foi encontrada a bolsa dispensada por Everton, a qual continha 96 (noventa e seis) porções de crack e 49 (quarenta e nove) eppendorfs de cocaína.

Interrogado em solo policial, o réu disse que: "as drogas lhe pertencem. Na noite anterior, estava num baile na comunidade do Canta Galo e no final resolveu dar carona para algumas pessoas que conheceu no local. Tais indivíduos nada sabiam sobre os fatos e somente estavam aproveitando uma carona. Quanto a droga, estava numa bolsa, escondida dentro do carro. As drogas seriam consumidas por sua pessoa, porquanto é usuário e não traficante. Não quer declinar a origem de tais substâncias, mas afirma que as esqueceu no carro ao invés de deixá-las em casa como sempre faz" (fls. 7-8).

Vinicius de Castro Ávila, policial militar, contou que: "estava em patrulhamento ostensivo de rotina pela rua Dom Manoel quando avistou um veículo realizando uma conversão proibida na via, motivo pelo qual resolveu realizar a abordagem. Após dar sinais de parada, o condutor do veículo acelerou e fugiu, iniciando-se acompanhamento. Na rua do Enxofre, o condutor do carro não conseguiu adentrar numa curva e subiu na calçada. O veículo desligou involuntariamente na sequência. Ocorre que, antes de os ocupantes serem abordados, o motorista do veículo jogou uma bolsa pela janela. No veículo estavam Everton, condutor; Taís, passageira; Alison e Marlon no banco de trás. Na posse dos agentes nada de ilícito fora encontrado. No entanto, na bolsa dispensada por Everton foram localizadas noventa e seis porções de crack e quarenta e nove porções de cocaína, bem como dinheiro em espécie. De maneira informal, Everton afirmou que toda a droga lhe pertencia. Os demais indivíduos, afirmaram que somente estavam aproveitando uma carona. O veículo foi apreendido administrativamente" (fls. 2).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Gabriel Magrini (fls. 3).

O menor Alisson Vinicius Aparecido da Silva narrou que: "na noite dos fatos foi até um baile no bairro Canta Galo, em conjunto com seus amigos Taís e Marlon. Na hora de irem embora, antes de adentrar em algum ônibus, o indiciado passou por eles e ofereceu carona. O implicado queria ficar com Taís e por isso ofereceu a carona. No trajeto foram abordados pela polícia militar. Não sabia que havia drogas no carro, sendo que nem ao menos havia visto a bolsa na posse do indigitado. Somente estava aproveitando uma carona" (fls. 4).

Marlon Denis de Souza Felipe relatou que: "noite dos fatos foi até um baile no bairro Canta Galo, em conjunto com seus amigos Alisson e Marlon. No final da festa conheceram o indiciado, o qual ofereceu carona para irem para casa. O indiciado não lhes levou diretamente pra casa, sendo que ficaram andando de carro até que foram abordados pela polícia militar. Viu o indiciado jogando uma bolsa para fora do carro, mas desconhece seu conteúdo. Não conhece o implicado e não sabia que tinha drogas no carro" (fls. 5).

Thaís Stefane da Silva Santana disse que: “na noite dos fatos foi até um baile no bairro Canta Galo, em conjunto com seus amigos Alisson e Marlon. Na hora de irem embora estava sem dinheiro e aceitou carona de um desconhecido. Provavelmente ele ofereceu carona pois havia se interessado por sua pessoa. O implicado não os levou para casa e ficou andando pelas vias de um bairro que desconhece. Em determinado momento foram abordados pela polícia militar. Não sabia que havia drogas no carro, sendo que viu quando o implicado tirou a bolsa de baixo do banco e a jogou na via. Somente estava aproveitando uma carona e não sabia que havia drogas no carro” (fls. 6).

Às fls. 49-52, juntada certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 0000301-66.2018.8.26.0599 – ameaça e lesão corporal – pena extinta em 14/3/2019; autos n.º 0005297-08.2014.8.26.0451 – tráfico – pena extinta em 9/11/2017; autos n.º 0010403-79.2020.8.26.0502 – ameaça e lesão corporal – trânsito em julgado para a Defesa em 3/7/2020; autos n.º 0032148-55.2012.8.26.0451 – roubo – pena extinta em 9/11/2017).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 16-17, fotografia de fls. 18, laudo de constatação preliminar de fls. 21-25 e laudo de exame definitivo de fls. 116-118.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Ouvido, inicialmente, a testemunha Marlon Denis de Souza Felipe. Estava na comunidade Canta Galo com Jully e Alyson, em um baile. Everton estava interessado na amiga Jully (apelido de Thaís) e ofereceu carona em seu carro. Os três ingressaram no carro de Everton, junto de outro amigo de Everton que, posteriormente, foi embora. O réu foi até a própria casa e pegou uma bolsa. O depoente e os amigos ficaram esperando no carro. O réu foi levá-los embora. No caminho, o réu fez viu a polícia e começou a fugir com o carro. Logo depois, acha que um quarteirão de distância, Everton perdeu a direção, subiu na calçada e jogou a bolsa. Ele e os amigos ficaram sem entender nada. Era a mesma bolsa que ele tinha pegado em casa. Ficaram 1 hora na abordagem. Contou aos policiais o que tinha ocorrido, mas eles ouviram “mais ou menos”. Depois foram levados à delegacia. Depois, os policiais revistaram a bolsa e disseram que encontraram droga, mas não sabe a quantidade. Não conhecia Everton.

b) Na sequência, foi ouvido Vinicius de Castro Ávila, policial militar. Estava em patrulhamento na região e viram um veículo realizando uma manobra proibida e dirigia em velocidade incompatível com a via. Deram sinal de parada, mas o indivíduo tentou fugir. Na Rua do Enxofre, ele perdeu o controle do carro, subiu na calçada e o carro desligou. Antes disso, ele jogou uma mochila. Feita a abordagem, depois viram que na mochila arremessada havia drogas. A bolsa foi jogada pelo motorista. Everton assumiu a propriedade das drogas. Ele era o motorista. Os demais passageiros disseram que estavam em um baile no Canta Galo e apenas pegaram uma carona. Não sabiam que na mochila havia entorpecentes. Perguntado sobre a quantidade de drogas, consultou suas anotações e confirmou que havia 49 porções de cocaína, 96 de crack e R\$50,00. Não soube dizer se o dinheiro estava na bolsa. Everton confirmou que as drogas eram dele e que os demais passageiros recebiam uma carona. Não conhecia Everton.

c) Por fim, foi interrogado o réu Everton Cristiano Lopes Roque. Confessou os fatos. estava no baile e ofereceu carona aos demais ocupantes do carro. Brigou com a esposa e teve uma recaída. Voltou a usar droga e também aceitou traficar para sustentar o vício. Chegou a vender droga no baile, algumas porções que tinha consigo. Na saída do baile, já tinha consumido droga e foi para casa pegar mais droga para consumir. Ia consumir drogas com amigos, em paradas no caminho. Quando viu a polícia, fugiu por estar embriagado e ter usado drogas. Realmente dispensou a bolsa. Assumiu aos policiais que a droga era sua e que as pessoas que estavam com ele não sabiam. É usuário de cocaína e crack misturado com cigarro. Atualmente está buscando a Deus e está conseguindo ficando sem usar droga. Antes de ser preso, ficou um bom tempo sem usar droga, mas teve uma recaída por conta da briga que teve com a esposa. não conhece os policiais e não tem nada contra. Conheceu Marlon e

Thais no baile, não tem nada contra.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

Tendo em vista a confissão do requerido e a sua consonância com as demais provas dos autos, passo a me manifestar acerca da dosimetria da pena.

a) Da pena-base

De rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a circunstância agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime diverso do fechado. Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador "[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada" (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:

Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

EVERTON CRISTIANO LOPES ROQUE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 08 de dezembro de 2021, por volta de 11h00, em via pública compreendida entre a Rua Dom Manuel, Rua do Enxofre e Travessa Salvador, n.º 173, nesta cidade e Comarca de Piracicaba/SP, trazia consigo e transportava, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 96 (noventa e seis) invólucros plásticos contendo crack, substância derivada da cocaína, com peso líquido de 9,6g (nove gramas e seis decigramas), e 49 (quarenta e nove) eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido de 12,8g (doze gramas e oito decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, o réu - que ostenta condenação definitiva por tráfico de drogas - trazia consigo e transportava, no veículo GM/Monza, placas BNL-1377, porções de crack e cocaína para comercialização.

Ocorre que, ao realizar manobra de trânsito proibida, foi interpelado por policiais militares em patrulhamento. Desobedecendo às ordens de parada, iniciou fuga pelas vias acima descritas.

Em dado momento, EVERTON subiu com o veículo na calçada e, diante do desligamento do motor e da aproximação policial, dispensou uma bolsa pela janela. Na sequência, foi abordado juntamente com outros três ocupantes do carro.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi localizado.

Nas proximidades, foi encontrada a bolsa dispensada por EVERTON, a qual continha 96 (noventa e seis) porções de crack e 49 (quarenta e nove) eppendorfs de cocaína.

Na Delegacia, o réu admitiu a propriedade das drogas, mas alegou que era para uso pessoal (fls. 07/08).

Os demais ocupantes do veículo disseram que estavam de carona e desconheciam a existência dos ilícitos no veículo (fls. 04, 05 e 06) - dois dos passageiros (fls. 05 e 06) presenciaram EVERTON jogando a bolsa pela janela antes da abordagem policial.

Em exame pericial, foi constatada a presença de cocaína nas substâncias apreendidas (auto de exibição fls. 16/17, foto fls. 18 e laudo pericial de constatação fls. 21/25).

Diante das circunstâncias, notadamente as condições pessoais do réu, a fuga, a tentativa de livrar-se da droga, o relato dos passageiros e a apreensão de porções de crack e cocaína em quantidade e forma incompatíveis com a mera alegação de uso pessoal, é certo que o réu trazia consigo e transportava os entorpecentes com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 91), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 95/96).

Notificado (fls. 101), o réu apresentou defesa prévia, na qual alegou inocência e pleiteou a revogação da prisão preventiva (fls. 105/108).

A denúncia foi recebida, mantendo-se a prisão cautelar e designando-se a audiência (fls. 119/121). O réu foi citado (fls. 148).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, na fotografia de fls. 18, no laudo de constatação de fls. 21/25 e no exame químico-toxicológico de fls. 116/118, segundo o qual foi detectada a presença de cocaína, nos materiais apreendidos.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu confirmou a propriedade das drogas. Afirmou que, na noite anterior, estava num baile na comunidade do Canta Galo e, ao final, resolveu dar carona para algumas pessoas que conheceu no local. Tais indivíduos nada sabiam sobre os fatos e somente estavam aproveitando uma carona. A droga estava numa bolsa, escondida dentro do carro, e seria consumida por ele próprio, porquanto é usuário e não traficante. Não quer declinar a origem das substâncias, mas afirma que as esqueceu no carro ao invés de deixá-las em casa como sempre faz (fls. 07/08).

Em Juízo, o réu afirmou que estava no baile e conheceu as pessoas, propondo-se a lhes dar uma carona. Levou os passageiros até sua casa. Passou pela sua casa, pegou o resto da droga que iria consumir. Quando viu a Polícia, ficou com medo de perder o carro e, por isso, correu. Tinha brigado com sua mulher e, por isso, comprou a droga. Teve recaída, entrou em depressão. Já tinha vendido drogas para pessoas no bairro. Vendeu a droga no baile que estava à noite. Depois, ficou com vontade de consumir mais drogas e foi até sua casa, para buscar mais. A droga da bolsa era para seu próprio consumo. Iria consumir toda a droga com os amigos. Jogou a bolsa com a droga para fora do carro, com medo de que os policiais pudessem fazer com ele. Os passageiros não sabiam que tinha droga na bolsa. Faz uso de cocaína e crack misturado com cigarro. Antes de ser preso, ficou muito tempo sem consumir drogas, mas teve recaída, em razão da briga com a esposa. Conheceu Marlon e Thais naquela noite.

A autoria ficou comprovada pelo restante da prova produzida nos autos. Vejamos.

O policial militar Vinicius de Castro Ávila narrou que estavam em patrulhamento, quando avistaram um veículo que efetuou manobra em alta velocidade. No intuito de fazer verificação de trânsito, se aproximaram do veículo, mas ele empreendeu fuga em maior velocidade. Em dado momento, o motorista perdeu o controle e subiu na calçada. Quando perdia o controle do veículo, o motorista dispensou uma mochila, para fora do carro. Fizeram a abordagem e, dentro da mochila, havia drogas. Havia

umas 05 pessoas no veículo. O motorista jogou a mochila e assumiu a propriedade do entorpecente. Os outros passageiros disseram que estavam num baile funk durante toda a noite e tinham pegado uma carona com ele, sem saber o que havia dentro da bolsa. Havia 96 porções de crack e 49 porções de cocaína. Também apreenderam R\$ 50,00. Não conhecia o réu. O réu confirmou a versão dos passageiros de que tinham pegado uma carona.

Marlon Denis de Souza Felipe asseverou que estava no Cata Galo com July e Alisson. Já era de manhã e o réu pediu uma carona, porque estava interessado em July. O réu estava de carro. Entrou no carro, juntamente com Alysson e July. Foram até a casa do réu. Ficaram no carro, o réu entrou na sua casa e saiu com uma bolsa. Ele entrou no carro novamente e iria levá-los para casa. Estavam no trajeto, quando o réu viu a Polícia e começou a correr. Só que o réu andou pouco com o carro, subiu na calçada e parou o carro, jogando a bolsa que tinha pegado na sua casa. Ficou sem entender o que estava ocorrendo. Foram abordados e contou o que tinha ocorrido. Não sabia o que havia dentro da bolsa. Os policiais encontraram drogas dentro da bolsa. Não conhecia o réu. July é o apelido da testemunha Thaís.

Ouvido apenas na Delegacia de Polícia, o depoimento do também policial militar Gabriel Magrini, segundo o qual estava em patrulhamento ostensivo de rotina pela rua Dom Manoel, quando seu parceiro lhe chamou a atenção para um veículo que desrespeitou ordens de parada. Na Rua do Enxofre, o condutor do carro não conseguiu adentrar numa curva, subiu na calçada e o veículo "morreu". Ocorre que, antes de os ocupantes serem abordados, o motorista do veículo jogou uma bolsa pela janela. No veículo estavam Everton, condutor; Taís, passageira; Alison e Marlon no banco de trás. Na posse dos agentes, nada de ilícito fora encontrado. No entanto, na bolsa dispensada por Everton, foram localizadas 96 porções de crack e 49 porções de cocaína, bem como dinheiro em espécie. De maneira informal, Everton afirmou que toda a droga lhe pertencia. Os demais indivíduos, afirmaram que somente estavam aproveitando uma carona (fls. 03).

Na fase policial, Thais Stefane da Silva Santana relatou que, na noite dos fatos, foi até um baile no bairro Canta Galo, em conjunto com seus amigos Alisson e Marlon. Na hora de irem embora, estava sem dinheiro e aceitou carona de um desconhecido. Provavelmente ele ofereceu carona, pois havia se interessado por sua pessoa. O réu não os levou para casa e ficou andando pelas vias de um bairro que desconhece. Em determinado momento, foram abordados pela Polícia Militar. Não sabia que havia drogas no carro, mas viu quando o réu tirou a bolsa de baixo do banco e a jogou na via. Somente estava aproveitando uma carona e não sabia que havia drogas no carro (fls. 06).

A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

Na fase policial, o réu confirmou a propriedade da droga. Em Juízo, o réu alegou que a droga lhe pertencia e a pegou em casa, porque iria consumi-la, com amigos. Os policiais militares narraram que estavam em patrulhamento de rotina pelo bairro, quando avistaram o veículo do réu realizando manobra proibida na via e, por isso, resolvendo abordá-lo. O réu não obedeceu à ordem de parada e fugiu. Durante o acompanhamento policial, o réu não conseguiu fazer uma curva, subiu em uma calçada e o motor do carro desligou involuntariamente, de forma que foi abordado. Antes da abordagem, contudo, os policiais presenciaram o réu jogando uma bolsa pela janela do veículo. As drogas apreendidas foram localizadas dentro da bolsa dispensada pelo réu, bem como dinheiro em espécie. Informalmente, aos policiais, Everton assumiu a propriedade das drogas. Os demais ocupantes do veículo informaram que estavam apenas pegando uma carona com o réu. Em Juízo, apenas Vinicius foi ouvido e confirmou o depoimento policial.

Marlon e Thaís estavam no interior do veículo e disseram que pegaram carona com o réu, na saída de um baile. Ambos confirmaram que viram o réu jogando a bolsa, na qual estava a droga, na via pública, antes da abordagem. Em Juízo, só Marlon foi ouvido e confirmou o que havia afirmado, na fase policial.

Com efeito, a localização da droga no interior da bolsa jogada pelo réu e sua responsabilidade por ela é fato que não possui contradição, na medida em que o próprio réu e as testemunhas o confirmaram.

Ainda que assim não fosse, deve-se dar crédito à palavra dos policiais militares, uma vez que como funcionários públicos que são, tem validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal. Ressalto que o depoimento dos policiais foi firme, unânime e inquestionável.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). (...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroborados por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018 - grifei).

Ressalto que os policiais não conheciam o réu e, se quisessem prejudicá-lo, não precisariam utilizar-se de quantidade expressiva de drogas, poderiam fazê-lo em quantidade menor.

Toda a prova, portanto, é suficiente para saber que a droga apreendida estava na posse do réu.

Assim, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprove a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da

prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11). No caso dos autos, o réu alegou que a droga era para seu próprio consumo. A prova confirma, contudo, a destinação descrita na denúncia.

Inicialmente, o réu não obedeceu à ordem de parada, demonstrando que estava na prática de conduta ilícita.

A quantidade de droga, sua diversidade e sua forma de embalagem (49 microtubos de cocaína e 96 invólucros de crack) indicam que a droga seria usada para consumo de terceiros pessoas, uma vez que usuários não mantêm essa quantidade de drogas consigo, transitando pela cidade.

Embora o réu tenha mencionado que é usuário de drogas, a quantidade era considerável e a situação profissional informada pelo réu no momento da prisão (desempregado), traz a certeza de que ele não teria condições financeiras para adquirir essa quantidade de entorpecente para seu consumo próprio.

O próprio réu informou que já tinha vendido algumas porções de drogas no baile onde havia passado a noite e, por isso, não se pode crer que fosse consumir toda aquela quantidade de drogas, fora do baile, depois que ele já tinha terminado.

Além disso, junto com a droga houve apreensão de dinheiro (R\$ 51,00), cuja origem lícita não foi confirmada.

Assim, as circunstâncias da prisão, as condições pessoais do réu, a fuga, a tentativa de se livrar das drogas, a quantidade e diversidade das drogas; tudo revela que a droga tinha como destino o consumo de terceiros pessoas.

Ressalto que ainda que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito.

Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câ. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor, não sendo cabível a desclassificação.

3) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Alegou a Defesa que condenações já alcançadas pelo período depurador não podem ser consideradas como maus antecedentes.

Ocorre, no entanto, que a condenação definitiva anterior à prática do delito que se julga tem no sistema penal duas situações distintas: se a extinção da pena ocorrer dentro de cinco anos antes da prática do novo delito, é considerada reincidência. Caso o cumprimento da pena seja superior a esse prazo, é caso de maus antecedentes. Afastar-se esse entendimento, seria excluir-se a figura dos maus antecedentes, havendo apenas reincidência, o que não é a intenção do legislador.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

(...) CONDENAÇÕES CRIMINAIS COM MAIS DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. (...) As condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes. (...) . (STJ - HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. ART, 44, III, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL DOS MAUS ANTECEDENTES. TESE DE NE BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão combatido esta de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois, no caso, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, porquanto inadimplido o inciso III do art. 44 do Código Penal, devido a existência de circunstância judicial desabonadora dos maus antecedentes. 2. Ademais, "a pacífica jurisprudência deste Tribunal estabelece que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal" (STJ - RHC 66.436/SP, FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 06/05/2016). 3. Quanto à tese de existência de ne bis in idem, alegando terem sido utilizados os mesmos fundamentos para fixar o regime mais gravoso e indeferir a substituição da pena, verifica-se que esse pleito não foi aventado em recurso de apelação às fls. 219-223 (e-STJ), o que não se admite nos embargos de declaração, por constituir inovação recursal, carecendo, portanto, a matéria do necessário prequestionamento. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 955.835/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017 - grifei). Apelação criminal - Furto - Absolvição por atipicidade material da conduta - Princípio da insignificância - Inadmissibilidade - Crime impossível - Inocorrência - A fiscalização dificulta, mas não impossibilita a consumação de furtos - Crime tentado - Inocorrência - Redução do acréscimo aplicado à pena-base - Inviável - O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do término da pena da condenação anterior e a data da infração posterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes - sanado de ofício erro material constante na dosimetria da pena - Inteligência do art. 11, do Código Penal - Recurso não provido. (TJSP - Processo: APL 00027237320118260691 SP 0002723-73.2011.8.26.0691 - Relator(a): Amaro Thomé - Julgamento: 09/10/2014 - Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 14/10/2014).

EMENTA FURTO QUALIFICADO MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS VERSÃO EXCULPATÓRIA CARENTE DE CREDIBILIDADE PENA E REGIME CRITERIOSAMENTE DOSADOS - FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO PISO BEM MOTIVADA RÉU QUE POSSUI DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO CONSIDERADAS COMO MAUS ANTECEDENTES REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO QUE SE MOSTRA ADEQUADO, NÃO SE ADMITINDO A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP - Apelação nº 0012632-28.2012.8.26.0361 - Relatora: Ivana David - j. 04/05/2016 - Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal).

Apelação. Porte de arma de uso restrito. Recurso defensivo postulando a revisão da dosimetria. Num primeiro momento, o STF já firmou o entendimento de que o aumento

da reprimenda pela reincidência está de acordo com o princípio da individualização da pena. Na forma do art. 64, inciso I, do Código Penal, ultrapassado o lapso temporal superior a 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, as condenações penais anteriores não prevalecem para fins de reincidência. Podem, contudo, ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59 do Código Penal. No caso em comento, não há se falar em bis in idem pela aplicação da agravante da reincidência e pela consideração de maus antecedentes, se existem 03 (três) condenações com trânsito em julgado, podendo duas serem consideradas na primeira fase e outra na segunda. De outro norte, o quantum de aumento aplicado em razão da agravante genérica de reincidência (1/5) mostra-se proporcional, considerando a gravidade do crime de latrocínio tentado constante de sua FAC. Entretanto, a exacerbação da pena-base e de multa é revista em nome do princípio da razoabilidade. Provimento parcial do recurso. (TJRJ - Processo: APL 01866870820138190008 RJ 0186687-08.2013.8.19.0008 - Relator(a): DES. MONICA TOLLEDO DE OLIVEIRA - Julgamento: 14/04/2015 - Órgão Julgador: TERCEIRA CAMARA CRIMINAL - Publicação: 20/04/2015 11:20 - Parte(s): Apelante: PEDRO CRISTIANO MENDES CHAVES - Apelado: MINISTERIO PUBLICO).

Apelação. Crime de Tráfico de Drogas. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a